

1500081-72.2022.8.26.0269

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... de um édito pelo delito de tráfico. Senão vejamos. I. DA NECESSIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. Excelência, cumpre observar que, após regular instrução probatória, restou comprovado que o acusado estava, de fato, portando as drogas apreendidas para uso pessoal, devendo-se reconhecer que a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

2ª Vara Criminal

Avenida Peixoto Gomide, centro, Itapetininga - SP - cep 18200-160

TERMO DE AUDIÊNCIA - VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:

1500081-72.2022.8.26.0269 - Controle 2022/000121

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO PEREIRA NUNES DOS SANTOS

Data da Audiência:

26/04/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes (inclusive do réu), verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Itapetininga, do representante do Ministério Público, do Defensor, o advogado Gustavo Roberto Camargo, OAB 431515/SP, e do Acusado Marcelo Pereira Nunes dos Santos. Na "sala virtual" permaneceram exclusivamente o Defensor e seu representado para contato prévio. Antes de serem inquiridas as testemunhas foram devidamente advertidas acerca da incomunicabilidade. Foram ouvidas as testemunhas Gustavo Henrique Gomes e Milton Martins de Almeida Júnior arroladas pelas partes e as testemunhas Salomão de Oliveira e Fabiana Alves de Oliveira Lima arroladas pela defesa. Em seguida o réu foi interrogado. Os depoimentos foram registrados pelo sistema Microsoft Teams. Pelas partes foi dito que não tinham diligências a requerer. Pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito que: Não havendo mais provas a serem colhidas, declaro encerrada a instrução, determino as partes que passem aos debates. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito: MM. Juiz, O réu foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pois, no dia 12 de janeiro de 2022, por volta das 17h, na Rua Bem-aventurado José Maria Escrivã, 14, Vila Prestes, nessa cidade e Comarca de Itapetininga, trazia consigo e guardava, para entrega posterior a consumo e fornecimento, ainda que gratuito, 01 tablete de "maconha", com peso de 32,42g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O réu foi notificado (fls. 86) e apresentou defesa prévia (fls. 91/92). A denúncia foi recebida em 11/03/2022 (fls. 93/94) e o acusado foi citado (fls. 110). Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. O réu foi interrogado. É este o breve relatório. Penso que a ação deve ser julgada procedente. A materialidade do delito restou comprovada

pelo boletim de ocorrência (fls. 06/07), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), auto de constatação (fls. 20/21) e pelo laudo do exame químico-toxicológico (fls. 114/117). A autoria também foi devidamente demonstrada. Vejamos. Em solo policial, o réu disse que comprou uma porção de "maconha" por R\$ 70,00 para seu próprio uso. Contou que escondeu o entorpecente quando avistou os policiais, pois ficou com medo. Disse que a droga foi localizada pelos militares (fls. 04). Interrogado em Juízo, disse que adquiriu a droga para o seu consumo. Pagou o valor de R\$ 70,00 por ela. Ao avistar a viatura, agachou-se para esconder o entorpecente. Foi abordado e, enfim, preso. Não disse em momento algum que a parte da droga seria vendida. Foi abordado alguns metros do local onde escondeu a droga. A prova oral é suficientemente segura ao incriminá-lo. De fato, diz a denúncia que policiais militares faziam patrulhamento e avistaram o denunciado abaixado em um matagal, local já conhecido como ponto de venda de drogas, o que gerou forte suspeita e motivou a abordagem. Assim que os agentes públicos se aproximaram de MARCELO já avistaram o tablete de "maconha", que foi apreendido. O denunciado foi abordado e, durante revista pessoal, os militares encontraram a importância de R\$ 179,50 em dinheiro. Indagado, informalmente MARCELO disse aos policiais que havia adquirido a droga por R\$ 70,00 e que iria vender parte dela para recuperar o "investimento". Pois bem. Agora, a testemunha Gustavo - policial militar - afirmou que patrulhava o local, quando viu o réu ao lado de um prédio, em uma área de mato, abaixado. O conhecimento do envolvimento do réu com o tráfico e a fama do local motivaram a abordagem. Na revista, foi encontrada com o réu a quantia em dinheiro. O local onde ele se encontrava, abaixado, abrigava a "maconha". O réu disse que a "maconha" era destinada ao seu uso e que iria vendê-la, em lascas, até ser ressarcido do valor que pagou por ela (R\$ 70,00). O policial Milton corroborou o depoimento do seu colega. Acrescentou que o acusado encontrava-se sozinho no local. A testemunha Fabiana - arrolada pela Defesa - relatou que o réu é seu vizinho. Disse que estava almoçando, em um trailer, quando viu a abordagem. Segundo ela, os fatos se deram por volta das 14:00hrs. Não soube explicar as contradições de seu depoimento (horário da abordagem). A testemunha Salomão relatou que viu o instante da abordagem. Afirmou que nunca viu o réu na prática do tráfico. Relatou que os fatos se deram por volta das 17:00hrs. Não viu a localização do entorpecente. Assim, a prova é firme ao incriminar o acusado. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga, a confissão informal, a apreensão de expressiva quantia em dinheiro e as demais circunstâncias do caso concreto atestam que a substância se destinava ao tráfico. Registre-se que nada está a indicar que as testemunhas da acusação estejam a prejudicar inocente ou a fantasiar sobre as circunstâncias do crime. Suas palavras foram firmes, harmônicas e coerentes, de modo que merecem todo crédito. A propósito, o mesmo não se diga das testemunhas arroladas pela defesa, que não se acertaram, sequer, sobre o horário da ocorrência. Dessa forma, os fatos narrados na inicial acusatória foram devidamente comprovados. Impõe-se, pois, a integral procedência da ação. Passemos, então, à análise da pena. Observo que o réu não ostenta maus antecedentes e é primário (fls. 28/32), apesar de já ter sido condenado pela prática do crime de tráfico de drogas. Cabe lembrar ser impossível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, em razão da condenação antes mencionada, que não é apta a gerar maus antecedentes ou reincidência, mas evidencia de forma clara a dedicação a atividades criminosas. Ademais, a grande quantidade de droga apreendida também demonstra o réu se dedicava a atividades criminosas, fazendo do narcotráfico meio de subsistência. Pelos mesmos motivos acima mencionados, o regime prisional deverá ser o inicialmente fechado e se mostra incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ante o exposto, requer e espera o Ministério Público a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, com decretação do perdimento dos valores apreendidos. Dada a palavra ao Dr. Defensor, foi dito: MM Juiz: Após a instrução probatória, verifica-se que a pretensão persecutória, tal como vertida na inicial, não merece prosperar, visto que as provas levadas aos autos não autorizam a prolação de um édito pelo delito de tráfico. Senão vejamos. I. DA NECESSIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. Excelência,

cumprir observar que, após regular instrução probatória, restou comprovado que o acusado estava, de fato, portando as drogas apreendidas para uso pessoal, devendo-se reconhecer que a capitulação do delito dada pelo Ministério Público, qual seja, a do art. 33 da Lei nº 11.343/06, mostra-se equivocada. O acusado fora surpreendido portando 26 gramas de maconha em uma única unidade, confirmando seu depoimento na delegacia, em Juízo, disse que a droga encontrada no momento do flagrante era para seu consumo próprio. Os depoimentos das testemunhas confirmam que o Réu de fato é usuário de entorpecente. Tais versões, Excelência, merecem credibilidade, visto que restaram contrariadas, apenas, pelo relato dos policiais que, data venia, houve contradição, sendo certo que o policial Gustavo afirmar que seu direito ao silêncio só fora feito na delegacia, afirmam ter o Réu confessado no momento da operação, contudo, está confissão restou incerta, bem como, ainda que tenha ocorrido, sabe-se que a confissão informal é rechaçada pela jurisprudência, nesse sentido: HABEAS CORPUS. PEDIDO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. WRIT NÃO CONHECIDO. PROVA ILÍCITA. CONFISSÃO INFORMAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA DESENTRANHAR DOS AUTOS OS DEPOIMENTOS CONSIDERADOS IMPRESTÁVEIS. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 5º, INCISOS LVI E LXIII. 1 - Torna-se inviável o conhecimento de habeas corpus, se o pedido não foi enfrentado pelo Tribunal de origem. 2 - A eventual confissão extrajudicial obtida por meio de depoimento informal, sem a observância do disposto no inciso LXIII, do artigo 5º, da Constituição Federal, constitui prova obtida por meio ilícito, cuja produção é inadmissível nos termos do inciso LVI, do mencionado preceito. 3 - Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (HC 22.371/RJ, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2002, DJ 31/03/2003, p. 275) (grifo nosso). No mesmo sentido, recentemente já se pronunciou o E. Tribunal de Justiça no sentido de não admitir a menção de uma confissão feita do Réu aos Polícias Militares como fundamento para uma condenação, in verbis: "Apelação. Comércio ilegal de munição. Sentença procedente. Recurso defensivo. Preliminar. Ilicitude probatória. Violação ao direito a não autoincriminação. Mérito. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Desclassificação para o delito previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/2003. Aplicação da suspensão condicional do processo. Pleitos subsidiários: a) fixação da pena no mínimo legal; b) aplicação do regime inicial aberto; c) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 1. Preliminar. Confissão informal quanto à comercialização ilícita das munições. Violação ao direito ao silêncio. Qualquer pessoa tem o direito de permanecer em silêncio, de não declarar qualquer informação que resulte em autoincriminação. Art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal e art. 8.2.g, da Convenção Americana de Direitos Humanos. Norma de eficácia imediata, direito que independe de regulamentação por norma infraconstitucional. Necessidade de advertência ao direito ao silêncio em qualquer fase da persecução penal e por qualquer agente estatal. Precedentes da Suprema Corte norte-americana, da Corte Interamericana de Direitos Humanos e dos Tribunais Superiores Pátrios. Inadmissibilidade da prova ilícita." (TJSP - 16ª Câmara Criminal - Ap. 1500308-45.2020.8.26.0556-- Rel. Marcos Alexandre Coelho Zilli - j. 01/06/21). Assim, não há nos autos indícios de que o acusado fosse comercializar a droga apreendida. Pelo contrário, o Réu esclarece que a droga em questão era para seu consumo pessoal desde seu interrogatório na delegacia, bem como em juízo sob o crivo do contraditório, bem como sua condição é confirmada por testemunhas que prestaram o devido compromisso com a verdade. Diante da ausência de demonstração do intuito lucrativo, não basta a simples apreensão do entorpecente em poder dos acusados para se justificar uma condenação pelo delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Nesse sentido: "Apelação Criminal - RECEPÇÃO e TRÁFICO DE DROGAS (...) Tráfico de Drogas. Inocorrência. Desclassificação para uso. Necessidade. A mera posse de entorpecente sem outros elementos concretos que indiquem o comércio ilícito é insuficiente para caracterizar a mercancia. Desclassificada a conduta, impõe-se o reconhecimento ex officio da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de uso de entorpecente. Prazo de 02 (dois) anos. Artigo 30 da Lei 11.343/2006. Penas impostas aos crimes de receptação. Alteração. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e multa. Presença dos requisitos legais. Artigo 44 do Código Penal. Regime aberto. Parcial provimento ao

recurso" (TJSP - 10ª Câmara de Direito Criminal - Apelação nº 0037520-31.2009.8.26.0114 - Des. Rel. Rachid Vaz de Almeida - j. 21/03/2013). E, também: "A apreensão de apreciável quantidade de tóxico, por si só, não basta ao reconhecimento da traficância" (TJSP - AC 35.88-3 - Rel. Gonçalves Sobrinho - RT 608/323 e RJTJSP 94/452). Dessa maneira, diante da ausência de evidências de que os acusados visassem a comercializar e obter lucro (circunstância inerente ao tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/06) deve prevalecer o entendimento de que a classificação jurídica correta para a conduta atribuída a ele é a do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, devendo-se operar, portanto, a desclassificação, com suas consequências legais. Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença:

Vistos. MARCELO PEREIRA NUNES DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 12 de janeiro de 2022, por volta das 17 h, na Rua Bem-Aventurado José Maria Escrivã, n. 14, Vila Prestes, nesta Cidade e Comarca de Itapetininga, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, um tablete de "maconha", com peso de 32,42 gramas. Notificado, fls. 86, o Réu apresentou defesa preliminar, fls. 91/92. A denúncia foi recebida, fls. 93/94, e o Réu citado, fls. 110. Durante a audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas presentes e realizou-se o interrogatório (gravação por videoconferência). Alegações finais apresentadas pelas partes, o MP pugnou a condenação e a Defesa, a absolvição. É o relatório. DECIDO. A ação é parcialmente procedente. A materialidade do delito de tráfico acha-se consubstanciada no Boletim de Ocorrência, fls. 06/07, no Auto de Exibição e Apreensão, fls. 09/10, no laudo provisório, fls. 20/21, bem como no Exame químico-toxicológico n. 12.068/2022, fls. 114/117, contatando-se a presença do princípio ativo tetrahidrocanabinol (THC). Gustavo Henrique Gomes e Milton Martins de Almeida Júnior, policiais militares, disseram que estavam em patrulhamento quando se depararam com o Réu abaixado em um matagal e, por ser ali local conhecido pelo tráfico de entorpecentes, fizeram abordagem, ele já tinha saído em caminhada, mas o pararam e encontraram no local onde ele estava abaixado um tablete de "maconha"; ao ser indagado o Acusado disse que tinha adquirido aquela droga e iria revendê-la para recuperar o dinheiro investido, e, se sobrasse alguma coisa, usaria. Também apreenderam quantia em dinheiro. Fabiana Alves de Oliveira Lima, testemunha, disse que almoçava, era por volta das 14 h, quando viu o Réu ser abordado e depois a apreensão da droga em outro local. Talvez fosse 17 h. Salomão de Oliveira, Testemunha, disse que tem um trailer e viu a abordagem do Réu, mas não viu a localização do entorpecente. Marcelo Pereira Nunes dos Santos, Réu, ao ser interrogado, disse que tinha ido à Vila Palmeira, onde adquiriu 25 g de "maconha"; ao voltar viu a viatura e, com medo dos policiais, abaixou-se, escondeu a droga e retomou a caminhada, quando foi abordado. Não confessou o tráfico de entorpecentes. Confrontando-se a prova coligida, verifica-se que a desclassificação é medida que se impõe. Com efeito, os policiais estavam em patrulhamento quando se depararam com o Réu, o qual estava abaixado em um terreno e, por se tratar de local conhecido por tráfico de entorpecentes, fizeram a abordagem, quando localizaram um tablete de "maconha", com peso de 32,42 gramas. O testemunho dos policiais é seguro e coerente, todavia o Réu, apesar da dúvida demonstrada quando da ciência da acusação, confessou que a droga apreendida lhe pertencia, porém aduziu que tinha adquirido o tablete na Vila Palmeira e a substância seria destinada ao seu uso. Apesar da confusão da testemunha Fabiana quanto ao horário, tanto o testemunho dela quanto o testemunho de Salomão devem ser prestigiados na medida em que ficou claro que se trata da mesma ação policial, porém ambas as testemunhas presenciaram somente a abordagem, não o primeiro momento em que o Acusado estava abaixado com a droga e depois saiu andando, consoante asseverado pelos próprios policiais, que o abordaram não no local onde a droga foi encontrada, mas alguns metros após. Ora, todos narraram os fatos de forma verossímil, logo é possível que o Réu tenha adquirido a droga em outro local e tenha se abaixado ao ver os policiais, isto com o objetivo de esconder o entorpecente e evitar condução à Delegacia de Polícia. O tablete de "maconha" não estava enterrado, portanto é possível que tivesse sido colocado no terreno no exato momento em que o Réu tinha visto os policiais. A droga

não estava partilhada, era um tablete, e a quantia, tratando-se de “maconha”, não é elevada, é compatível com o uso pessoal, e o Réu não foi visto no atendimento de usuários. Não se olvida a suposta confissão informal, mas esta é insuficiente para a condenação por tráfico de entorpecentes, daí porque a questão da observância das garantias constitucionais no momento da prisão no local pelos policiais, não prevista no CPP, mas conforme jurisprudência, suscitada pela Defesa, não tem relevância neste caso sob análise. Em síntese, em virtude de todas essas circunstâncias, não se autoriza a prolação de decreto condenatório por infração ao artigo 33 da Lei de Drogas e mister é a desclassificação da conduta imputada ao Réu para a tipificada no artigo 28, da Lei n.º 11.343/06, o que faço com fulcro no artigo 383 do Código de Processo Penal. II – DA DOSIMETRIA DA PENA. (Art. 59, inc. II, do Código Penal). Fixada a responsabilidade do Acusado, passo à dosimetria da pena. ART. 28, DA LEI 11.343/2006: Atento às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal e aos critérios contidos no artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 aplico ao Réu a pena de advertência. III – DECIDO. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e o faço para DESCLASSIFICAR a imputação contida na denúncia e o faço para condenar, MARCELO PEREIRA NUNES DOS SANTOS, qualificado nos autos, a pena de ADVERTÊNCIA, dando-o como incurso no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06. Dá-se a pena por cumprida. Defiro a liberação do dinheiro. Sem condenação nas custas. O Réu estava e, neste momento, à vista da pena aplicada, poderá interpor eventual recurso em liberdade. Expeça-se alvará de soltura, com urgência. Sentença publicada em audiência. Cumpra-se. A presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19. O Termo de Audiência ficará disponível no sistema SAJ, ficando os presentes intimados do prazo de 5 (cinco) dias para interposição do recurso da sentença, dispensada a assinatura das partes, por se tratar de processo digital - sistema SAJ (Artigo 1.269 das NSCGJ). Nada Mais. Itapetininga, 26 de abril de 2022. Eu, (Marina Alice Correa de Almeida), Escrevente Técnico Judiciário digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA